

1502546-39.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502546-39.2021.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 5 de abril de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502546-39.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JEFFERSON FORTUNATO REIS e outro

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

HENRIQUE DOS SANTOS CONCEICAO e JEFFERSON FORTUNATO REIS, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 29, "caput", do Código Penal porque, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 23h40min., no bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

- 15 g de maconha, contendo a substância tetrahidrocannabinol, divididos em 13 invólucros plásticos;

- 1,8g de cocaína, na forma de crack, divididos em 20 frascos plásticos;

- 25,08g de cocaína em pó, divididos em 63 microtubos plásticos do tipo Eppendorf;

- 21g de lança perfume, contendo a substância cloreto de metileno/diclorometano,

divididos em 2 frascos plásticos e;

- 30g de K2, divididos em 18 porções (fls. 92), além da quantia R\$ 96,00 (noventa e seis reais), em notas fracionadas, fruto da venda de tráfico de drogas, encontrada em poder de Jeferson.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da denúncia, condenando-se os réus nos exatos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, requereu seja reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa com relação a ambos os réus, a qual não pode diminuir a pena aquém do seu mínimo legal; cabível a redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Ademais, requereu a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente com relação ao acusado Jeferson. Por fim, requereu seja determinada a perda da quantia em dinheiro apreendida, em favor da União.

A Defesa do corréu Henrique, por seu turno, requereu absolvição pela a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; a fixação do regime ABERTO para cumprimento da pena (com fulcro nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e artigo 387, §2º do CPP – preso desde 21/10/2021 – fls. 71/73 – mais de cinco meses nesta data), bem como que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (artigo 44, do CP); e o direito de o réu apelar em liberdade.

Já a Defesa do acusado Jefferson manifestou-se contra as alegações ministeriais e pugnou pela restituição do dinheiro apreendido.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, comprovante de depósito de fl. 96, laudos de exame químico toxicológico de fls. 97/99, 102/106, 113/115 e 119/123, que resultaram positivo para maconha, crack, cocaína e CLORETO DE METILENO/ DICLOROMETANO, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, além de ADB-BUTINACA, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o acusado Jefferson, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que não tem relação com o tráfico de drogas e que correu quando da abordagem policial porque se assustou. Não sabia que eram policiais, pois não estavam identificados. O dinheiro apreendido consigo era fruto de seu trabalho. Conhece o corréu Henrique, pois moram próximos. É usuário de maconha.

Já o corréu Henrique, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que é usuário de maconha e estava no local dos fatos para comprar drogas. Disse que, na data dos fatos, estava em sua casa, quando Jefferson ligou e foram comprar maconha juntos. Jefferson estava voltando do trabalho na ocasião. São vizinhos. Disse que quando os policiais chegaram, os meninos que estavam traficando correram e soltaram a sacola de drogas no chão.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o corréu Henrique confessou a prática delitativa quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova hoje produzida, notadamente pelo depoimento dos policiais envolvidos em sua prisão.

O acusado Jefferson, por sua vez, silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

Desta forma, a negativa de ambos em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa.

O depoimento judicial dos policiais envolvidos na prisão dos acusados, ressalto, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar os réus injustamente, com uma estória fantasiosa. Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Importante destacar, ainda, a considerável quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, além de R\$ 96,00 (noventa e seis reais), em dinheiro trocado, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a

prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Ressalto, entretanto, que no presente caso, foi visualizada pelas testemunhas a conduta típica da comercialização do entorpecente, com o acusado Jefferson sendo abordado por um transeunte, que lhe entregou dinheiro e recebeu do corréu Henrique, o entorpecente.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo drogas para fins de tráfico.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada aos réus para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química dos réus, nada explica a presença de tamanha quantidade e variedade de drogas em via pública.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que os réus são tecnicamente primários e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo suas penas no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante genérica da menoridade relativa com relação a ambos os acusados. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Ademais, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em $\frac{1}{2}$ (metade), estabelecendo-as em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, penas estas que torno definitivas ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o acusado não tem vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano

seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, os réus iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR HENRIQUE DOS SANTOS CONCEICAO e JEFFERSON FORTUNATO REIS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado com relação ao acusado Henrique.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o corréu Jefferson ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA